

1500361-50.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico, se preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem da pena.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500361-50.2021.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500361-50.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2166069/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 18593189 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1642/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2166069 - DEL.POL.SALTO, 1642/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE LUIS PIO BOTELHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu JOSE LUIS PIO BOTELHO, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 18 de junho de 2021, por volta das 23h55min, na Rua Marechal Rondon, nº 2938, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Salto/SP, o acusado, em ocasião de calamidade pública, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 18 (dezoito) porções de "cocaína", com peso líquido de 11,37g (onze gramas e trinta e sete centigramas); e b) 01 (uma) porção de "maconha", com peso aproximado de 13,91g (treze gramas e noventa e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 16 de agosto de 2021 (fls. 55-58).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 73-75).

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fl. 79-82) e o réu citado.

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas comuns.

Os pedidos de instauração de incidente de dependência toxicológica foi apreciado e indeferido pela decisão de fls. 79-82, que transitou em julgado.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-04), auto de exibição e apreensão (fl. 05), auto de constatação preliminar (fls.06) e laudo de exame químico toxicológico (fls.49-51) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais Diego Guiaro de Moraes e Robson Silveira Barbosa, em síntese, relataram que estavam em patrulhamento pela Rua Marechal Rondon, bairro Santa Cruz, local é conhecido como ponto de venda de drogas, quando observaram um indivíduo que ao notar a presença da guarnição, soltou no chão um embrulho plástico de cor branca. Abordado, foi revistado e identificado como sendo José Luis Pio Botelho e em seu bolso localizada a importância de R\$60,00 em dinheiro. O embrulho recuperado continha 18 pinos plásticos transparentes acondicionando cocaína e uma porção de maconha. Questionado, negou a propriedade das drogas, afirmando ser usuário de crack e que estava pelo local para comprar drogas. O investigado não soube precisar a quantidade do dinheiro que tinha na ocasião.

O réu não compareceu, sendo revel, vide certidão em fls. 105 e 108.

O réu, na fase inquisitiva (fls. 09), disse, em resumo, que não estava vendendo drogas e tinha acabado de fazer uso de crack do qual é dependente. O dinheiro que trazia consigo é proveniente do recebimento de sua quinzena do trabalho como pedreiro.

Os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu trazia consigo a droga e após aproximação dos agentes de segurança foi visto dispensando no chão um embrulho plástico de cor branca contendo os entorpecentes embalados e prontos para comercialização.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e guardas municipais podem realizar prisão em flagrante. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilicitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômodo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida.

Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1

ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021).

Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, certo é que as circunstâncias da prisão, o tipo e variedade de drogas, denotam o intuito mercantil e, corroborados pelos demais depoimentos colhidos em Juízo, são suficientes a embasar o decreto condenatório. Além disso, deve ser observado que o réu, na fase inquisitiva disse ser usuário de crack, o que também foi dito aos guardas civis, mas no momento da abordagem ele dispensou uma sacola contendo droga diversas, cocaína e maconha. No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes coma recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminoso e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP: Apelação Criminal 1512067-20.2020.8.26.0228; Relator (a): ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Barra Funda, 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021).

À luz do princípio da proporcionalidade, segundo recente entendimento do STJ, as condenações anteriores pelo delito de posse de droga para uso próprio não servem para configurar reincidência ou antecedentes criminais que, conquanto seja crime, comporta penas menores, jamais privativas de liberdade, sendo desproporcional produzir um efeito tão rigoroso. Nesse diapasão:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AGRAVANTE AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E

NATUREZA DOS ENTORPECENTES. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em relação à agravante do art. 61, I, do Código Penal, ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm decidido ser desproporcional o reconhecimento da reincidência decorrente de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, cuja inobservância não acarreta a aplicação de pena privativa de liberdade e a constitucionalidade está sendo debatida no STF. 2. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 3. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na quantia e na variedade das substâncias apreendidas - 26,22 de cocaína e 166,32g de crack -, assim como nos demais elementos constantes dos autos, que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. AgRg no HC 602.724/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).

Por fim, cabe ressaltar que partir do julgamento do HC 97.256 pelo STF, quando foi declarada incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 33 e do artigo 44 da Lei de Drogas, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico, se preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem da pena.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não devem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes agravantes e atenuantes.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu JOSE LUIS PIO BOTELHO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Concedo a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet.

Publique-se e intime(m)-se.
Oportunamente, ao arquivo.

Salto, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA